耕地保护:从管制到补偿

■李凤章

现有以计划指标和用途管制为主要手段的耕地保护模式,存在较大局限,有限的耕地补偿因缺乏权利基础也并未成为国家的法律义务。可通过权利机制实现耕地保护,承认集体土地所有权人或者承包经营权人拥有土地开发权。规划禁止的是开发行为,不能在未补偿情况下自动剥夺耕地权利人的开发权。开发权人在开发受限制的情况下,可以要求补偿或者转让开发权实现利益。地力补偿与开发权补偿不同,二者可以并存。

[关键词]耕地保护;开发权补偿;地力补偿

[中图分类号]D922.3 [文献标识码]A [文章编号]1004-518X(2023)05-0125-11

[基金项目]上海市决策咨询研究项目"上海实施乡村振兴战略立法调研"(2021-Z-G01)

李凤章,上海大学法学院教授、博士生导师。(上海 200444)

耕地保护是我国的基本国策。早在1997年,中共中央、国务院《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发〔1997〕11号)就明确指出:"我国的土地管理特别是耕地保护措施必须是十分严格的。"2008年,《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出:"坚持最严格的耕地保护制度,层层落实责任,坚决守住十八亿亩耕地红线。"2019年《土地管理法》修正,将"基本农田"上升为"永久基本农田"。2020年9月,国务院办公厅《关于坚决制止耕地"非农化"行为的通知》,严格禁止八种耕地非农化的行为。同年,国务院办公厅《关于防止耕地"非粮化"稳定粮食生产的意见》,要求坚决防止耕地"非粮化"倾向。当前《耕地保护法》的立法工作也正在加快推进。但耕地保护的压力依然巨大。2021年公布的国土"三调"数据显示,"二调"(二调完成于2009年)以来的10年间,全国耕地地类减少了1.13亿亩。

一、现有耕地保护的基本模式

政策不断完善强化而效果并不理想,这就需要我们对现有的耕地保护制度进行反思。实际上,历经30余年的发展,我国耕地保护制度已经形成了自己的特色模式。

(一)以行政审批的用途管制为主

我国的耕地保护,脱胎于计划经济时代,仍然保持着浓厚的行政审批色彩。一旦土地被确定为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

耕地,则其向建设用地的转化,必须获得行政部门的审批。并且,这种审批权,正不断地集中于省级和中央人民政府。《土地管理法实施条例》第24条规定,农用地转为建设用地,涉及占用永久基本农田的,由国务院批准;不涉及占用永久基本农田的,由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准。至于市县人民政府,其职责是根据建设用地单位的申请,拟定农用地转用方案,并报省级人民政府或者国务院批准,以及对经批准的转用方案,组织实施。在整个土地转用程序中,耕地转用本身并不需要考虑土地权利人的意愿,除非因存在着征收而需要和土地所有权人进行协商。土地用途管制其实是中央或省级政府对下级政府的管理和审批, 基本排斥了具体用地需求者和集体土地权利人的利益诉求。审批程序通常都被理解为内部行政程序,不具有可诉性。[1]

(二)以各类指标为主要管制工具

指标一直是我国政府进行经济调控的重要手段, 耕地保护目标的实现也采取了指标配置的管理方式。[2]根据《土地管理法》第23条、第24条的规定,自然资源部根据全国土地利用总体规划,确定未来一定时间的总体用地指标,然后分配给各个省、自治区、直辖市。各个省、自治区、直辖市再根据本地实际情况,确定每年的年度土地利用计划指标,地方政府只有在取得建设用地指标的情况下,才可以将耕地转为建设用地。除了建设用地指标外,还有耕地保有量指标、基本农田指标等。而能否取得建设用地指标的关键,一是国家批准的某地可以利用的新增建设用地指标总数,二是其后的占补平衡,即必须保持一个地方的耕地总量不减少。中央政府对地方耕地保护任务完成情况的检查和考核,也以指标为依据。指标成了政府实现耕地保护目的的一项工具,中央政府正是通过指标的分配、分解、检查等来落实对具体用地行为监管的。[1]同样,地方政府在落实耕地保护任务,实现占补平衡时,也主要借助指标的量化管理模式对下级进行约束和考核,一方面将耕地保护指标分解到下级政府,层层明确责任,另一方面,为了实现占补平衡,也往往规定通过土地整治确定能够复垦从而可以增加的耕地数量。基于指标的量化管理成为耕地行政保护的主要工具。

(三)责任追究机制不断得到强化

关于耕地保护,已经形成了包括刑事处罚、行政处罚、纪律处分在内的责任体系和追究机制。《刑法》第342条规定了非法占用农用地罪。《土地管理法》第74条、75条、76条则分别规定了对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地,违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂等行为的行政处罚,包括责令恢复原状、行政罚款等。2008年6月1日起实施的《违反土地管理规定行为处分办法》,由监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部联合发布,规定行政机关及其公务员有不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地,没有土地利用计划指标擅自批准用地;没有新增建设占用农用地计划指标擅自批准农用地转用等行为,对有关责任人员,给予记过或者记大过处分;情节严重的,给予开除处分。为了及时发现违法行为和追究责任,早在2006年,自然资源部就根据《国务院办公厅关于建立国家土地督察制度有关问题的通知》建立了专门的土地督察制度,向地方派驻9个国家土地督察局;并且在2009年建立了违法占地线索的举报机制,设立了12336国土资源违法线索举报平台等。督察局成立以来,不断加大土地督察力度,每年都会选择典型违法案例予以公布。2021年,自然资源部又印发了《关于完善早发现早制止严查处工作机制的意见》,提出“推动建立‘田长制’,实现县乡村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管”。由各级地方政府的负责人担任各级田长,强化地方政府领导保护耕地的责任,不断强化监管和考核。

(四)奖补对象主要是地方政府

现有耕地保护政策中确实也有奖励和补贴措施。2022年,农业农村部办公厅、财政部办公厅联合印发通知,明确中央财政实施产粮(油)大县奖励、稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴、耕地地力保护

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

补贴、实际种粮农民一次性补贴、大豆玉米带状复合种植补贴。[①]上述奖补措施,包括两大类型。其一,针对粮食主产区地方政府的区域补偿。粮食主产区补偿是国家对耕地保护区和粮食主产区的区域补偿。近年来多个中央一号文件明确提出,要发挥粮食主产区优势,完善粮食主产区利益补偿机制,健全产粮大县奖补政策。2020年农业农村部在《对十三届全国人大三次会议第1042号建议的答复》中提到,为缓解粮食主产区财政困难,国家对粮食生产达到一定规模的产粮大县进行奖励。2020年,中央财政安排产粮大县奖励资金466.7亿元人民币,较上年增加17.14亿元。该答复强调补偿的目的是缓解粮食主产区财政困难,显然补贴的对象主要是地方政府,而非具体农户。针对的也是区域,而非具体耕地地块。其二,地票交易实际上也是国家对耕地保护区的一种市场化补贴形式。由于我国坚持耕地总量的占补平衡, 从而形成了实践中的地票交易制度, 即复垦区将建设用地复垦为耕地,增加了耕地指标,建设区则使用该增加的耕地指标占用本区耕地进行建设,并向复垦区支付地票对价。重庆的地票价格现在已经达到每亩30万元人民币。[3]除重庆等少数地区探索在地票交易中对农户进行补偿外,土地复垦的主体一般是地方政府,地票交易的受益方因此一般也是地方政府。对集体和农户的补偿,主要是上述地力补偿和种植特定粮食作物的补偿。地力补偿,是对土地权利人采取积极措施,保持和提高土壤肥力和耕地质量的激励性补贴。例如农业农村部办公厅《推进生态农场建设的指导意见》(2022年)规定,要以生态农场为重点对象,探索秸秆还田、有机肥施用、深松整地为重点的地力补偿政策。种粮补贴等,则是因种植特定农作物而给予种植者的激励性补贴。二者的金额均较为有限。

二、目前耕地保护制度存在的问题

上述模式,脱胎于计划经济,带有浓厚的行政管制色彩,已经越来越难以适应经济社会发展的实践,也难以实现耕地保护的制度目的。

(一)单纯指标管理难以保障耕地质量

在指标控制模式下,国土部门出台了占补平衡的规定,相应地产生了地票交易制度,即某一地区建设用地复垦后增加的耕地数量,可以被另一个开发建设地区使用,从而该开发建设地区可以占用相应数量的耕地。但复垦区土地质量与地票落地区耕地质量存在差异,如田坎系数、坡度等不同;复垦的区域甚至属于采煤深陷区复垦、灾毁地复垦等,这些地区土地的土壤质量和开发区域建设占用的耕地质量,相差甚远。[4]而恰恰土地质量,对于粮食生产至关重要。为此,《土地管理法》第37条规定,禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂等。禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。2020年,国务院办公厅《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》提出,禁止占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物, 禁止占用永久基本农田从事林果业以及挖塘养鱼、非法取土等破坏耕作层的行为。2022年9月5日,自然资源部发布的《耕地保护法(草案)》(征求意见稿)第17条规定,永久基本农田一经划定,不得擅自占用或者改变用途。严禁通过擅自调整国土空间规划等方式规避永久基本农田农用地转用或者土地征收的审批。实际上意味着即使拥有转入的地票,永久基本农田也不得擅自被改变用途。

从简单的指标管理,到注重耕地本身的质量,这标志着耕地保护的一个重大转变,更能实现通过保护耕地实现粮食安全的目的。但挑战随之而来,数量指标的控制,相对较为容易,因为耕地是否被转为建设用地,是否从事建设开发,较为容易判断。我们甚至依赖于卫星的探测即可发现。自然资

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

源部目前有十多颗卫星,利用遥感影像这项技术,对耕地利用情况进行全方位监督检查。每个月卫星都可以覆盖一次,而且自然资源部也可以根据工作需要,随时对某一个区域、某一个地块进行抽查。②但是,发现破坏耕地质量的行为却要困难得多。禁止非农化、非粮化的有关文件中,特别强调要禁止占用永久基本农田从事林果业以及挖塘养鱼、非法取土等破坏耕作层的行为,禁止闲置、荒芜永久基本农田。利用永久基本农田发展稻渔、稻虾、稻蟹等综合立体种养,应当以不破坏永久基本农田为前提。但荒废闲置的土地长满了荒草,耕地种植花卉水果等经济作物,导致基本农田受破坏的立体养殖,想利用卫星发现则要困难得多。这种情况下,耕地的保护质量,更有赖于土地占有使用人的自觉行为以及地方政府和社会的日常监管。而要实现这一点,单纯地靠管制和惩罚恐怕难以奏效。

(二)政府角色冲突掣肘耕地保护

一方面,地方政府负有保护耕地、维护粮食安全的责任;另一方面,地方政府又承担着发展经济的重任,为了发展经济,很多时候就要依靠投资建设,而投资建设就往往意味着要占用土地,很多时候就是要占用耕地。而且,现有的征地制度,对集体土地的征收是按照农用地的价格进行补偿,而地方政府在取得集体土地所有权后则以商业或者住宅用地等用途进行招、拍、挂出让建设用地使用权。用途之间的差异,导致了巨大的出让收益,地方政府也因此形成了对土地出让收益的依赖,即所谓的土地财政。财政部官方网站公布的统计数据显示,2021年,国有土地使用权出让收入87051亿元,同比增长3.5%。在这种土地财政依赖和发展经济的压力背景下,地方政府违法征收耕地的冲动一直难以得到遏制。例如,2009—2017年南充市政府通过违规将集体土地确权为国有土地、将农用地确权为未利用地等方式,违法批准征收7748.24亩集体土地(其中耕地6007.83亩)。③2019年10月,汕尾市海丰县海城镇政府违法占用海城镇温厝村5.96亩土地,其中5.36亩永久基本农田,建设"茶艺一条街"。2012年开始,临汾市涝洹河生态指挥部违法批准征收屯里镇、乔李镇等乡(镇)土地7838.89亩,开挖水面1782.61亩(其中占用耕地598.35亩);违法占地594.81亩(其中耕地296.24亩)建设国学馆、广场、古镇等。2014年7月以来,扬州市未经批准陆续擅自占地908.02亩(其中耕地654.47亩,涉及永久基本农田377.17亩)建设廖家沟城市中央公园等13个公园。④农业农村部党组成员兼中央农村工作领导小组办公室秘书局局长吴宏耀也指出,虽然为加强耕地保护,国家先后颁布了《土地管理法》《基本农田保护条例》等多部法律法规,相继出台了一系列严格耕地保护的政策措施。但一些地方有令不行、有禁不止,耕地"非农化"现象在不少地区仍然突出。⑤政府的监管任务和经济发展任务,存在相互掣肘的情形,这严重影响了政府对耕地保护监管职责的发挥。

(三)补偿金额较低无法形成有效激励

通过激励机制,建立行为人的内部自觉,是保障管制有效实现的前提。管制是有成本的,有效的管制,必须要获得及时准确的必要信息,且执行者能够严格执行。但恰恰是管制者在具体违法行为人的种种伪装下,很难及时发现信息,而执法过程中也往往因为执法者的寻租等,导致执法行为难以准确实施。为了实现有效管制,应首先培育行为者的自觉。同时,确保针对少数的违法行为,管制者能够集中人力物力,及时发现,严厉制裁。而要培育耕地占有使用人的自觉保护,就必须对其因保护耕地而遭受的损失进行合理的补偿,使其获得相对均衡的收益。但目前的补偿标准远远低于农民所遭受的损失。蔡银莺、余元以江夏区五里界镇为例,证明基本农田保护区的设立,农民土地发展权的年均机会损失在3763.35–5426.47元/hm^2。[5]代冬梅、杨皋伶等以重庆为例,根据公式计算得出发展权损失角度下,永久基本农田保护补偿价格应为34361元/亩。[6]但《2022年重庆市耕地地力保护和种粮大户补贴工作实施方案》显示,种粮大户种植一季主要粮食作物(包括水稻、玉米、小麦等12种粮

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

食作物),原则上种植面积50亩(含50亩)以上,每亩仅补贴230元。补偿金额显然是偏低的,不足以产生激励作用。[6]农业农村部的统计数据则显示,近几年耕地地力保护补贴,亩均补贴约95元,户均补贴约564元。⑥这种低价,也降低了农民自身土地的权利价值,从而在地方政府或者开发企业非法占地时,无法形成有效的遏制。至于建设用地复垦后形成的地票转让收入,也基本上是地方政府或者集体经济组织所得。虽然也有试点地区如重庆,探索将收益直接分配给具体享有承包经营权的农户,但该试点做法尚未有效铺开。更多的情况是,政府让村民集中上楼,这一过程中,政府会通过房屋置换或者货币补偿等方式,对村民给予补偿,地票收入一般也用于新居民区的建设,或者公共设施的配套等,一般很少将出售地票的收益直接给农户,而是主要在集体经济组织和政府之间分配。

(四)不利于耕地权利人具体保护义务的确立和履行

一方面,由于补偿的缺位,农民不但无法形成自己保护耕地的激励,而且,也无法通过为国家设立地役权而确定自身具体的耕地保护义务。法律只是规定了一般意义上的耕地保护义务,强调农户不得从事建设开发以及其他破坏耕地地力的行为,但这种义务只是规范意义上的普遍性义务,并不针对具体的土地承包经营权人,也没有获得其同意。如果其他人违法用地行为广泛存在,本着法不责众的想法,土地承包经营权人就会置法律的规定于不顾。

另一方面,补偿的作用不仅仅是为了激励,更重要的是在于通过补偿,使被补偿人在接受补偿的同时,也因此承担其具体的保护耕地的义务,从而也为补偿人建立起一种具体的权利,使权利人可以据此要求耕地使用人履行义务,并在其未能履行义务时追究其法律责任,从而更好地保护耕地。例如,根据民法役权制度的规定,国家对耕地的开发利用进行限制,并支付补偿,从而获得针对耕地的役权,而耕地的权利人在役权法律关系中负有不得从事开发建设的义务,如果其不履行义务,国家不仅作为土地管理者可以依法处罚,还可以作为役权人,依照民事程序要求其履行义务。这种役权的制度设计,不仅可以让耕地权利人明确自身的义务,也为役权人赋予了要求义务人履行义务的请求权基础,从而更好地实现保护目的。补偿以及相应权利机制的欠缺,使得耕地保护只能依赖国家的强制制裁,从而大大降低了保护效果。

三、开发权限制:国家耕地补偿的法理依据

基于基本农田在维护农业生态和粮食安全方面的功能,国家作为公共利益的代表,应负有补偿的义务。[7]但国家义务的基础是什么,如果不把这一义务建立在被补偿人的权利之上,以至于并不存在一个可以依据权利要求国家补偿的主体和机制,国家的这种补偿义务,就只能是一种政治性义务或者道德义务,耕地权利人缺乏要求其履行的能力或者可能。一边是法律上用途的严格管制,一边是国家的象征性补偿,则耕地权利人的利益仍无法得到保障。所以,如果要在法律上夯实国家的补偿义务,并且赋予耕地的农户要求国家补偿的权利,就必须为农户的这种权利寻找请求权基础。换句话说,国家补偿,是因为农户的何种权利受损?

这种权利,在法律上应该是开发权。土地开发权(Land Development Rights)是对土地在利用上进行再开发的权利,即在空间上向纵深方向发展、在使用时变更土地用途之权。[8]开发权,是由土地所有权的本质性内涵所决定的,即土地所有权意味着用途的非限定。所有权人的权利是不可能以列举的方式加以确定的,法只以否定的方式界定所有权的内涵,确定对物主宰权的一般约束,即规定法律限度。[9](P148)罗马法上有言:一个人可以在不犯他人的情况下对自己的物为所欲为。[10](P204)1804年法国民法典第552条规定:土地的所有权,即意味着包括地上所有权与地下所有权。土地所有权人得于

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其地上进行其认为合适的任何栽种与建筑,但“役权与地役权”编所规定的例外,不在其限。[11](P173)开发权也往往通过救济彰显出来，例如美国法上有管制性征收制度。霍姆斯在1922年Pennsylvania Coal Co.V.Mahon 案中说,至少一般的规则是,虽然财产可以在一定程度上被管制,但是如果这种管制走得太远,就会被认定为一种征收。⑦土地分区管制制度是为了达到某些公共利益而从土地所有权人处夺走了部分财产权。以农业区为例,分区管制是禁止该等土地转变成住宅用地使用的机会,即取走了该部分的财产权。[12]

由于土地的占有并没有发生变化,而只是开发利用受到了限制,因此,受限制或者说被夺走的只能是土地开发权。一旦承认了农民对土地的开发权,那么限制耕地使用人对耕地进行开发给耕地权利人造成不合比例的价值减损时,就应对耕地权利人给予补偿。只有补偿的金额,足以让耕地权利人即使不开发,也能获得一份相对均衡的收入,耕地权利人才会被激励保持耕地不被开发。

但给予补偿可能超出了国家的财力。为了解决这一问题，我国可以借鉴美国的开发权转让制度,允许耕地占用人将开发权通过市场进行交易。根据开发权转让模式,一个区域的土地被划分为开发区与保存区,保存区的土地所有权人拥有土地开发权,开发区土地所有权人如果要超出规定的开发密度开发土地,需要从保存区土地所有权人手中购买土地开发权。通过开发权的交易,保存区的土地所有权人取得转让对价,作为对开发权受限制所遭受损失的补偿。[13]我国的地票交易制度和开发权转让有相似之处,但亦有不同。现有地票交易,交易的是耕地占地指标,即购买者可以利用购买的地票,在保持占补平衡的情形下,将地票确定面积的耕地转为建设用地。其针对的是复垦形成的新耕地,而非存量耕地;地票受让人取得的是占地资格,而非提高原有建设用地的开发密度。但地票所代表的开发权,其法理是一致的。我们完全可以将地票从增量耕地扩展到存量耕地,承认存量耕地的权利人拥有土地开发权，并且可以将土地开发权转让给那些需要提高开发密度或者依法需要新占耕地的人。

需要解决的问题是,既然立法已经限制了耕地的开发利用,为什么还会承认耕地权利人享有土地的开发权?笔者认为,理由如下。

(一)集体土地所有权与国家土地所有权的同权同能

权利概念是对权利内涵的外部表达,如果概念的名称是同一的,在同一个法律体系内,权利的内涵就应该保持一致,这是制度体系逻辑自洽的基本要求。国家土地所有权和集体土地所有权,既然都被民法规定为土地所有权，二者的权利内涵就应该是一致的，承认国家土地所有权人可以开发,或者将开发的权利出让给使用权人,那么,就必须承认集体土地所有权本身包含了开发权,农民集体可以将开发权出让或者转让。在政策实证方面,2013年十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》也明确规定:“在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价。”在法律实证方面,2019年修订后的《土地管理法》第63条,也改变了原有第63条禁止集体土地建设用地使用权出让给集体外第三人使用的做法,允许集体经营性建设用地入市,并且规定,集体经营性建设用地的出租,集体建设用地使用权的出让及其最高年限等,参照同类用途的国有建设用地执行。集体土地所有权人,既然可以像国有土地一样出让不同用途的建设用地使用权，足可见至少在行为上我国也已经承认了集体土地和国有土地在开发权上的同权同能。

(二)农户是否享有耕地开发权取决于集体的赋权程度

应该说,目前的立法确实并未规定集体将集体土地的开发权赋予承包经营权人,承包经营权人只能将承包地用于承包合同约定或者法律规定的农业生产或粮食种植。根据我国土地使用权的生

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成逻辑,使用权出让之时,权利人取得的权利都是根据出让合同单一限定的,不同的用途还有不同的使用权年限,用途变更还需要办理使用权出让合同的变更程序,并补缴相应的出让金。农地承包经营权,虽然名为发包,实际上只不过是集体对农户土地使用权的出让,同样的法理逻辑,也很难说承包经营权人享有土地开发权。因此,不乏学者认为,我国土地权利人并不享有土地发展权,更谈不上对土地发展权的限制。⑧[7]但同时我们也应该认识到,承包经营权目前正沿着不断强化的趋势发展,无论从公共政策还是理论上,都存在集体土地所有权人将土地开发权赋予具体承包经营权人的趋势。

在时间上,《土地管理法》2019年修订时在第13条明确增加:家庭承包的耕地的承包期为三十年,草地的承包期为三十年至五十年,林地的承包期为三十年至七十年;耕地承包期届满后再延长三十年,草地、林地承包期届满后依法相应延长。在这种情况下,承包经营权人对土地的权利越来越大,土地始终在承包经营权人的占有和控制之下,集体将开发权赋予始终使用土地的承包经营权人,并允许其以转让或者补偿的方式实现开发权,获得相应的利益,无疑有利于激励耕地的占有使用人保持耕地地力。

实践中,例如重庆的地票交易,已经强调权利补偿的天平逐步向农户倾斜。根据《重庆市地票管理办法》第29条规定,地票交易的净收入,85%被分配给宅基地使用权人,而集体得到的只有15%。早在2009年,国土资源部文件中就呈现出将土地开发权赋予个人的倾向。2009年国土资源部《关于全面实行耕地先补后占有关问题的通知》中就明确规定,鼓励有条件的企业或个人依据土地利用总体规划和管理有关要求,利用自筹资金或结合生产建设活动,组织实施土地整理复垦开发项目补充耕地;耕地指标通过市场有偿转让,用于建设占用耕地的占补平衡。由于我国企业和个人不可能拥有土地所有权,允许企业和个人实施土地整理复垦成耕地,从而获得耕地指标,就意味着企业或者个人作为土地使用权人,可以拥有土地指标所代表的开发权,本质上就是某种程度上承认了使用权人对开发权的拥有。有学者还提出了农民进城带土地指标的建议,即农民在迁入城市时,可以带一定单位的土地指标,并以之置换城镇的户籍、住房、社保等。[14]时任南京市建邺区人民政府副区长的宗仁也撰文建议,地票跟随农民进城,向进城农民提供保障房的城市(人口流入地)从农民所属地(人口流出地)获得"地票"。[15]这实质上都是承认农户作为使用权人,拥有至少是部分的土地开发权。

(三)集体土地所有权在耕地保护规划实施前既已存在

规划对于财产权的内容和实现无疑起着重要的作用。尤其是中国土地使用权出让体系下,国有土地使用权出让,首先要满足规划条件,规划条件实际上也构成开发权的内容,土地的开发权及其限制都是通过将规划条件纳入出让合同确定的。

但集体土地所有权在规划制度实施之前,既已存在。虽然早在20世纪50年代,国家政策就已经有开展农村土地规划的要求,如1958—1962年间,根据第二个五年计划的发展要求,全国广泛开展了人民公社土地规划工作,主要任务是适应新的劳动组织和机械化、电气化的发展。[16]但耕地保护规划的实施,还只是20世纪80年代改革开放以后的事情。1982年1月1日,中共中央批转《全国农村工作会议纪要》,强调要切实注意保护耕地和合理利用耕地。1986年3月,中共中央、国务院印发《关于加强土地管理、制止乱占耕地的通知》,将"十分珍惜和合理利用每寸土地,切实保护耕地"确定为基本国策,并要求抓紧制定《土地管理法》。1986年国家颁布了第一部《土地管理法》,其第15条规定,各级人民政府编制土地利用总体规划。第3条规定,各级人民政府必须贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的方针,全面规划,加强管理,保护、开发土地资源,制止乱占耕地和滥用土地的行为。1988年,湖北省原荆州地区监利县划定全国第一块基本农田保护区,首次提出了"基本农田"的概念。1993年

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《全国土地利用总体规划纲要》提出建立基本农田保护区。1998年国务院颁布《基本农田保护条例》，提出将粮、棉、油生产基地内的耕地划入基本农田保护区，初步形成了对基本农田实行特殊保护的制度框架。可见，对耕地进行保护和划定基本农田，是在国家赋予集体土地所有权之后多年的事情。承认了这一时间上的先后顺序，此前开发上的无规划无限制，就应该成为集体土地所有权的应有内涵。

(四)既存权利不因后有规划未经补偿而自动消灭

首先，这是权利稳定性和登记确定性的要求。基于物权法定和公示公信要求，权利类型获得确定并且办理了登记后，就应该根据该名称确定权利的权能。外部规划的改变，不应该同时改变权利的内涵。否则，当规划改变时，权利类型和权利名称没变，其内涵却已经发生了变化，这就使得此前法律对权利类型及其内涵的界定丧失意义。例如，同样一块土地，此前是耕地，由甲享有农地使用权或者承包经营权，并且办理了登记，后来规划变更为建设用地，而在这一过程中，土地使用权人并没有发生变化，土地使用权的登记也没有发生变化，如果认为权利随之发生变化，就混同了外部的限制和内部权利的权能，严重影响权利的稳定，也使得登记难以实现对物权的公示，所谓物权法定就成为一句空话，严重危及交易安全，大大增加了交易时的调查成本。实践中，类似的规划变更，也并不改变权利内涵。例如，如果是工业用途的建设用地使用权，并不会因为土地规划改为住宅区就变为住宅用途的建设用地使用权。权利变更要遵循权利变更的法律要求，如变更出让合同、补缴出让金等。可见，决定权利内涵的应该是权利本身，而不是外部的规划改变。相同的权利类型，在内涵上应该是相同的，并且除非经过法定的权利变更或者变动，不能因为外部规划的改变，或者土地用途的改变而改变。

其次，未经征收补偿，既有开发权不会因为规划限制而消灭。对于规划限制，要区分权利自身的当然限制和国家为了实现公共目的而施加的限制。前者是权利的内在限制。任何权利都不是绝对的，基于民法上的相邻关系，为了方便彼此相邻土地权利人的土地利用，以及为了维护建筑设施的安全等，国家必然对土地利用本身进行一些必要的限制，这源于民法上物权妨碍排除或者危险消除的内在要求。规划只不过把权利的内在限制明确化。另一种是国家为了公共利益而对土地利用的外在限制。既然是为了维护公共利益，就没有理由要求被规划限制人个人承担公共利益的成本。如果这种限制导致的利益减损超出了个人利益享有的相应比例，就应该根据为公共利益而征收的基本要求，通过补偿取得原权利人的权利。万江对此明确指出，为什么那些处于农业保护区的村民必须承担粮食安全环境保护的所有成本？由于土地用途管制，限制了土地权利人自由处分其土地使用权利并进而影响其收益，土地用途管制构成了一种实质意义上的征收。[17]如果将禁止耕地开发视为征收，则意味着被征收人享有土地开发权，也意味着如果没有补偿，那么开发权仍然保留在原权利人手中。当然，这并不意味着法律的限制不起作用，而只是说，法律限制的只是行为，被限制人固然不得违反法律或者规划从事开发行为，但其始终保留着原有的开发权利。权利的拥有和权利的实现并不相同，对于开发权人来说，规划和法律的限制，使其不得从事具体的开发行为，但其可以基于该开发权受限制，而向国家寻求补偿。也可以把开发权放在市场上出售，实现利益的转化。即使在一定时期内缺乏实现的条件，权利也只是处于蛰伏状态，不能因此说权利自动消灭。否则国家单方面的立法或者规划限制，未经补偿就可以剥夺此前赋予土地权利人的权利，这使得对征收是否符合公共利益和是否完成补偿缺乏最基本的审查，既不符合公共利益征收的法理，也不利于限制国家权力和规划的任意，某种程度上也是国家对此前赋权契约的一个违反。⑨

所以，对于耕地保护而言，规划或者法律禁止耕地被开发建设，只是禁止了开发建设的行为，并

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不能剥夺土地的开发权。一方面,集体土地所有权人可以基于其开发权而要求国家补偿,或者将开发权转让实现价值。国家如果缺乏足够的财政能力直接补偿,不妨在借鉴美国开发权转让制度基础上,通过设立开发权转入区和转出区,建立开发权交易市场,通过市场机制为耕地所有权人或者承包经营权人找到价值实现的途径。另一方面,承认目前集体土地的开发权仍然属于集体所有,乃是因为集体出让或者发包给农户的承包经营权,目前仍然是用途单一的,但随着农户土地承包经营权越来越强大, 仍可以相信未来的趋势是开发权或者开发权的大部分收益逐步归属于具体使用耕地的农户。

四、维持地力补偿与开发权限制补偿的并存

有学者质疑通过开发权补偿保护耕地的正当性,认为在社会主义公有制背景下,集体和农户不可能拥有开发权,转而提出了地力保护作为补偿的基础。因为农户承担了保护地力的义务,因此应该得到补偿,他们认为"基本农田质量的保护不但要求农户消极的'不为',更重要的是如何激励农户积极的'为'"。[7]依据地力提升理论,基本农田保护补偿的受偿主体应是切实有助于地力提升的基本农田保护者。承包基本农田的农户直接在基本农田之上从事农业生产,是基本农田地力的"养护者"和农业生态利益与粮食安全利益的生产者,而农户从农业生产中所获的收益与由其生产的为全社会所享有的利益相比存在巨大的利益差距。因此,我国应将其作为受偿主体,维护直接从事基本农田保护者的合法权益。[7]

这一逻辑将农户补偿请求权,置于义务履行对价的地位,只有农户证明自己保持了土地地力,其才可以要求国家补偿。而这一地力的保护,不仅仅在于没有改变土地用途,更在于其从事了秸秆还田、休耕、使用有机肥等行为。这已经超出了此前不做什么的限制程度,而增加了积极义务的履行。在这种情况下,国家显然应该给予补偿,但这并不排除在农户消极不将土地用于开发建设时的补偿,二者可以并存。开发权补偿是对限制开发的补偿,地力补偿是对土地承包经营权人采取措施提高和维持地力给予的补偿。《耕地保护法(草案)》(征求意见稿)第18条也规定,国家提倡和鼓励农业生产者对其经营的永久基本农田施用有机肥料,合理施用化肥和农药。利用永久基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。可见,地力补偿是与肥料和农药的使用密切相关的,体现为耕地权利人的积极主动义务。耕地权利人没有履行上述义务,也就不能要求补偿,更不可能将要求补偿的权利出售实现价值。相反,如果是承认农民的开发权,则在国家没有财力补偿的背景下,可以允许开发权人将土地开发权所体现的容积率,在开发地区转让,从而通过市场实现开发权。因此,不能以地力补偿的重要,作为否定限制开发补偿的理由。实际上,实践中地力补偿和以种粮补贴体现出来的耕地补偿也往往是并存的。

而且,地力保护,实际上涉及如何改良土壤质量,而改良土壤质量和保持耕地不被开发是截然不同的两个问题。坚持耕地不得非农化和非粮化,未必就不会损害地力。例如大规模使用化肥和农药,尽管短期内粮食可能保持增长,但可能在较长时间破坏了土壤结构,导致土地板结和土地污染等,降低了地力。而能够提高地力的措施,根据农业农村部《推进生态农场建设的指导意见》规定,包括秸秆还田、有机肥施用、深松整地,广义上还包括化学农药减量、农膜回收利用等。该文件还专门提到了探索秸秆还田、有机肥施用、深松整地为重点的地力补偿政策。再者,耕地补偿,是因为对耕地禁止开发,农户遭受损失,如果不予补偿,建设开发利益的巨大诱惑会导致耕地承包经营权人改变土地用途。属于鼓励耕地权利人不去做不利于耕地的事。而地力补偿,则是在大量粮食生产与农

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

业生产者滥用化肥和农药等破坏地力的情况下,激励耕地承包经营权人采取措施,提高土壤质量,做有利于耕地的事。二者相差甚大,补偿当然也可以并存。

建立地力保护补偿,体现了人们对粮食安全保障的认识更上一个台阶,从简单地禁止非农化非粮化,到关注粮食的质量安全及改善土壤环境。未来,有必要建立专门的耕地土壤保护制度,科学规定能够提高地力的行为,并针对这些行为建立专门的奖励制度。

五、结语:对《耕地保护法(草案)》(征求意见稿)第52条的完善建议

《耕地保护法(草案)》(征求意见稿)在第52条规定,国家建立耕地保护补偿制度,对耕地和永久基本农田保护任务重、耕地保护目标责任完成好、粮食产量和粮食商品率高的地区和承担耕地保护任务的集体经济组织、国有农场等给予奖补。其仍然是行政管理取向的奖励措施,之所以补偿,并非因为被补偿人的土地开发权受限制,从而所有的耕地权利人,无论大小,无论身份,均应平等地适用补偿机制;而是因为这些集体经济组织或者国有农场,落实耕地保护目标责任较好。对耕地保护目标责任完成好坏的判断,必然依赖于上级主管部门的主观判断。这与以权利及其补偿为基础的法治路径显然有异。同时,其被补偿人,也主要是集体经济组织和国有农场,并未明确具体承包经营权人是否可以获得补偿,而恰恰耕地主要是由具体的承包经营权人在具体从事耕地的占有使用,集体经济组织和国有农场, 更多的是土地的发包方或者土地和生产的管理者, 激励对象仍然偏重于管理者,其对具体占地的承包经营权人的激励作用,恐极为有限。建议做如下修改:

第一,国家建立耕地保护补偿制度,对耕地权利人因耕地禁止开发而遭受的损失给予补偿。积极推进开发权市场交易制度,允许耕地权利人将无法实现的开发权通过市场出售获取收益,开发权的受让方可以根据购买的开发权在原有规划批准基础上相应增加开发建设的容积率等。

第二,耕地补偿的对象是耕地的集体土地所有权主体和承包经营权人;国有耕地的使用权人和承包经营权人。各地可以根据具体情况明确制定承包经营权人所占的开发权转让收益或者补偿的比例,承包经营权人所占开发权转让收益或补偿比例一般不得低于50%。

第三,国家建立耕地土壤质量提升制度,规定改善土壤质量提高耕地地力的具体措施,对于积极履行耕地土壤质量提升义务的耕地权利人,予以奖励。

注释:

①参见农业农村部《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00496号提案的答复》(农业农村部官方网站http://www.moa.gov.cn/govpublic/CWS/202208/t20220817_6407095.htm)。

②参见自然资源部部长王广华在国务院新闻办公室、国务院办公厅对《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》的吹风会上所做的介绍(自然资源部官方网站https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202009/t20200919_2558935.html)。

③参见自然资源部办公厅关于《四川省南充市人民政府违法批地案通报》(自然资源部官方网站http://gi.mnr.gov.cn/202007/t20200722_2534078.html)。

④参见自然资源部《对挂牌督办的11起土地违法案件调查的处理意见》(自然资源部官方网站https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202102/t20210207_2610352.html)。

⑤参见吴宏耀在国务院新闻办公室、国务院办公厅对《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》的吹风会上所做的介绍(自然资源部官方网站https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202009/

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

t20200919_2558935.html)。

⑥参见农业农村部《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00496号提案的答复》(农业农村部官方网站http://www.moa.gov.cn/govpublic/CWS/202208/t20220817_6407095.htm)。

⑦Pennsylvania Coal Co.V.Mahon,260 U.S. 393(1922).

⑧有些学者将开发权(Land Development Rights)翻译为发展权。

⑨当国家通过法律或者具体的契约,将土地权利赋予农民集体或者个人时,本质上是在国家和被赋权人之间建立了一个赋权契约关系,被赋权人享有了权利,也因此承担了义务,包括税收缴纳等,而国家则承诺保护被赋权人权利的稳定。这一点典型地体现在土地使用权出让合同中。当然,集体作为土地所有权人,一方面从国家手里获得土地所有权的赋权,另一方面,由于集体本身无法直接组织生产,而又把土地使用权赋予具体农户,从而在农民集体和具体农户之间,也建立起类似于国家和集体之间所有权赋权的法律关系。

[参考文献]

[1]黄忠.迈向均衡:我国耕地保护制度完善研究[J].学术界,2020,(2).

[2]康晓琳,施祖麟.基于指标调控的土地管理运行机制研究[J].公共管理评论,2013,(2).

[3]方涧.地票制度下的土地发展权:价值回归与功能续造[J].时代法学,2022,(5).

[4]项树明,邹士鑫,郑畅.对新型城镇化背景下地票交易制度风险防范的思考——以重庆市地票交易为例[J].经济研究导刊,2014,(23).

[5]蔡银莺,余元.基本农田规划管制下农民的土地发展权受限分析——以江夏区五里界镇为实证[J].中国人口·资源与环境,2012,(9).

[6]代冬梅,杨皋伶,田锋.发展权受限角度下永久基本农田划定中补偿价格的测算——以重庆市为例[J].国土与自然资源研究,2021,(2).

[7]吴胜利.关于基本农田保护补偿的法律规制[J].理论探索,2012,(5).

[8]李凤章.土地开发权:保护模式与权利归属[J].社会科学,2015,(4).

[9]彼德罗·彭梵得.罗马法教科书[M].黄风,译.北京:中国政法大学出版社,2005.

[10]黄风.罗马私法导论[M].北京:中国政法大学出版社,2003.

[11]法国民法典[M].罗结珍,译.北京:中国法制出版社,1999.

[12]郭洁.土地用途管制模式的立法转变[J].法学研究,2013,(2).

[13]Richard L. Barrows,Bruce A. Prenguber.*Transfer of Development Rights: An Analysis of a New Land Use Policy Tool*.American Journal of Agricultural Economics, 1976,(4).

[14]池芳春.统筹城乡土地指标筹措农民进城定居资金[J].经济体制改革,2014,(1).

[15]宗仁,姚明霞.农民成员权与宅基地制度改革探索[J].上海国土资源,2017,(4).

[16]林坚,赵冰,刘诗毅.土地管理制度视角下现代中国城乡土地利用的规划演进[J].国际城市规划,2019,(4).

[17]万江.土地用途管制下的开发权交易——基于指标流转实践的分析[J].现代法学,2012,(5).

【责任编辑:叶　萍】

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net